

刑法

No42

H20-7

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 甲は、乙が所有する木造家屋に乙が現在しているものと思って、同家屋に放火し、これを全焼させたが、実際には同家屋はだれも現在していない空き家であった。この場合、甲には現住建造物等放火罪が成立するが、その刑は非現住建造物等放火罪の刑による。

イ. 甲は、男性の乙が、酩酊して暴れ回る女性の丙を取り押さえているのを目撃し、乙が丙に対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し、丙を助けるため、乙の腹部をゴルフクラブで数回強く殴打するなどの暴行を加えて重傷を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えていた場合、甲には傷害罪は成立しない。

ウ. 甲は、乙に対する殺意をもって、乙の背後からけん銃を発射したところ、乙は赤ん坊の丙を抱いており、銃弾が乙の身体を貫通した後、丙にも命中して、乙及び丙の両名を死亡させた。甲が、乙に抱かれている丙の存在を認識していなかった場合でも、甲には乙及び丙に対する殺人罪が成立する。

エ. 甲は、公務員乙がその法令上の職務Aを執行するに当たり、乙が執行している職務がそれとは別の法令上の乙の職務Bであると誤信して乙の顔面を手拳で殴る暴行を加えた。乙の執行する職務が職務Bでなく職務Aであると分かっていたら、甲は上記暴行には及ばなかったという事情があった場合でも、甲には公務執行妨害罪が成立する。

オ. 甲は、客観的にはわいせつな文書を、その意味内容は理解したものの、その程度の性的描写であれば刑法上の「わいせつな文書」には該当しないと判断し、同文書を販売した。この場合、甲にはわいせつ物頒布等罪は成立しない。(改)

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

ア 誤っている

本記述では、甲はだれも現在していない空き家に乙が現在しているものと思って放火しており、抽象的事実の錯誤が問題となる。この点、判例は、法定的符合説に立っており（最決昭 61.6.9、百選 I 43 事件）、構成要件が重なり合う限度で犯罪の成立を認めている。本問において、甲は現住建造物放火罪（108 条）の故意で、他人所有非現住建造物放火罪（109 条 1 項）の結果を発生させている。ここで、現住建造物放火罪と他人所有非現住建造物放火罪の構成要件は客体の現住性の有無が異なるのみで、建造物に放火するという点で重なり合うので、軽い他人所有非現住建造物放火罪の限度において実質的に重なり合っているといえる。よって、甲には他人所有非現住建造物放火罪（109 条 1 項）が成立することとなる。

イ 誤っている

本記述では、甲は乙が丙に対して無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し、丙を助けるため乙に相当性を超える暴行を加えており、いわゆる誤想過剰防衛の処理が問題となる。この点、空手三段の腕前を有する被告人 A が、男性 B が酩酊している女性 C をなだめている際、C が尻もちをついたのを目撃して、B が C に暴行を加えているものと誤解し、自己及び同女の身体を防衛するため、回し蹴りをし後日死亡するに至らせたという事案において、判例は、「本件回し蹴り行為は」「防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかである」とし、「いわゆる誤想过剰防衛に当たるとして刑法 36 条 2 項により刑を減輕した原判断は、正当である」としている（最決昭 62.3.26、百選 I 29 事件、英国騎士道事件）。すなわち、犯罪が成立した上で刑が任意的に減輕される（36 条 2 項）こととなる。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行為者に過剰性の認識・予見がある場合、誤想した急迫不正の侵害に対する対抗行為を行った行為者の主観面は、現実存在する急迫不正の侵害に対する過剰防衛の場合と同じであり、したがって責任の程度もそれと同じであるから、過剰防衛に関する 36 条 2 項の規定を適用して刑の減免の余地を肯定することができることを挙げている。これによると、36 条 2 項による減免の余地はあるが、甲には傷害罪が成立することとなる。

ウ 正しい

大判昭 8.8.30。本記述では、甲は、乙に対する殺意をもってけん銃を発射し乙及び丙を死亡させており、方法の錯誤における併発結果について故意が認められるかが問題となる。この点、判例は、被告人 X が A を殺害する意図で、日本刀により A を十数回突き刺し、それにより A とともに A が抱いていた女兒 B を死亡させたという事案において、人を殺害する意思をもって暴行を加えて人を殺害した以上は、たとえその殺害の結果が犯人において少しも意識しなかった客体の上に生じたときであっても、暴行と殺害との間に因果関係があることが明白である以上、犯人が殺人既遂の罪責を負うべきことは当然であるとして、X に A 及び B に対する殺人罪の成立を認めている。これによると、甲には乙及び丙に対する殺人罪が成立する。

エ 正しい

本記述では、甲は、公務員乙が職務 A を執行するにあたり、職務 B であると誤信して乙に暴行を加えており、具体的事実の錯誤が問題となる。この点、判例は、法定的符合説に立っており（最判昭 25.7.11（百選 I 91 事件）、最判昭 53.7.28（百選 I 42 事件）等）、構成要件が重なり合う限度で犯罪が成立することとなる。本問のように、甲が法令上の職務を執行している乙に対して暴行を加えた場合、甲が職務 A を職務 B と誤信していたとしても、公務員が適法な職務を執行するにあたり、

これに対して暴行を加えるという同一の構成要件に該当するから、甲には公務執行妨害罪(95条1項)が成立する。

オ 誤っている

本記述では、甲は、客観的にはわいせつな文書を、刑法上の「わいせつな文書」に該当しないと判断して同文書を販売しており、規範的構成要件要素の錯誤が問題となる。この点、被告人が出版物に性的描写のあることを知りながら当該出版物を出版したという事案において、判例は、「刑法175条(現刑法175条1項)の罪における犯意の成立については問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、かかる記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要としているものでない。かりに主観的には刑法175条(現刑法175条1項)の猥褻文書にあたらないものと信じてある文書を販売しても、それが客観的に猥褻性を有するならば、法律の錯誤として犯意を阻却しないものといわなければならない」としている(最大判昭32.3.13、百選147事件、チャタレイ事件)。